

1501479-83.2021.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... gramas de maconha, para fins de tráfico.

Ainda, segundo a exordial, o acusado, no dia 29 de dezembro de 2021, na Rua Uruguai, número 1-65, bloco 03, apartamento 65, no bairro Jardim Terra Branca, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, mantinha em depósito cinco invólucros, ou 4.690 gramas de maconha, para fins de tráfico.

Boletim de ocorrência (fls. 27/29), auto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501479-83.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501479-83.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2353907/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 22196499 -

DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 10414/21/050 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2353907 -

DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2353907 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 10414/21/050 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL HENRIQUE PALMA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Gabriel Henrique Palma da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 29 de dezembro de 2021, às 17h, na Rua Pernambuco, número 11-46, bairro Parque Paulistano, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, trazia consigo um invólucro, ou 59,73 gramas de maconha, para fins de tráfico.

Ainda, segundo a exordial, o acusado, no dia 29 de dezembro de 2021, na Rua

Uruguai, número 1-65, bloco 03, apartamento 65, no bairro Jardim Terra Branca, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, mantinha em depósito cinco invólucros, ou 4.690 gramas de maconha, para fins de tráfico.

Boletim de ocorrência (fls. 27/29), auto de exibição/apreensão (fls. 30), laudo de constatação preliminar (fls. 33/39) e laudo definitivo (fls. 108/111).

Pelo crime, foi o acusado preso em flagrante.

Durante a análise da formalidade do ato (fls. 84/87), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva.

Pela decisão de fls. 119/121, foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado.

O réu foi, formalmente, citado (fls. 172), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 124/126).

Na decisão de fls. 131/132, houve a manutenção do recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 226/228 foram ouvidas as testemunhas PM Renato Pereira Rossini, PM Abraão Junior da Silva Neves e Nayara de Oliveira Cesario. Na mesma ocasião, a D. Defesa desistiu da oitiva da testemunha Francine Paiva, pleito homologado. No mesmo ato processual, foi deferida a oitiva da genitora do acusado (Liene) como testemunha do juízo.

Na audiência em continuação de fls. 259/261, foi ouvida a testemunha do juízo e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 266/273 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da exordial, com a valoração do art. 42 da Lei nº 11.343/06, da personalidade e conduta social (tendo em vista o acusado estava em 'saída temporária de Natal'), o reconhecimento da reincidência específica e da agravante do "estado pandêmico", afastando-se a benesse prevista no art. 33, §4º da Lei Antidrogas, ficando-se o regime inicial fechado.

Já a D. Defesa Constituída, às fls. 277/288, pleiteou, em síntese, pela absolvição por falha no arcabouço probatório, ou a desclassificação para o delito de consumo pessoal, com a possibilidade de recurso em liberdade. Pleiteou, ainda, pela expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar e pela instauração de inquérito, por crime que teria sido praticado pelo Sgt. Abraão Junior da Silva Neves (art. 342, §1º do Código Penal).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 27/29), auto de exibição/apreensão (fls. 30), laudo de constatação preliminar (fls. 33/39) e, em especial, pelo laudo definitivo (fls. 108/111).

A autoria, na mesma senda, induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Em juízo, a testemunha policial militar Renato Pereira Rossini, em resumo, disse que estavam em patrulhamento, quando receberam 'denúncia' de populares no sentido de que, na rua Pernambuco, havia um indivíduo, sem camiseta e usando bermuda. Identificaram o acusado. Em busca pessoal, encontraram porção de maconha de 70 gramas. O réu autorizou a entrada da equipe na residência. Pediram o apoio do canil. O réu Gabriel estava em gozo de benefício de 'saída temporária'. O réu disse que, na residência da genitora, havia outra quantidade de drogas. Foram na residência localizada na rua Uruguai, onde a genitora do réu autorizou a entrada da equipe policial. Encontraram uma mochila, a qual continha 414 quilogramas. Na primeira residência, estava a esposa do Gabriel. A esposa do Gabriel permitiu a entrada da equipe. Foi feito o vídeo de sua autorização. A genitora também autorizou a entrada. Gravaram as autorizações. Não sabe a distância existente entre as duas residências. O réu foi abordado numa rua movimentada. Quem filmou foi outro policial. Era o terceiro integrante da equipe e, por isso, não se recorda do horário da gravação. A mochila estava no quarto da irmã do réu. Não se recorda quanto tempo duraram as diligências no apartamento da genitora do acusado.

Em juízo, a testemunha policial militar Abraão Júnior da Silva Neves, em síntese, afirmou que estavam em patrulhamento pelo bairro, quando receberam 'denúncia

anônima' no sentido de que havia um indivíduo, em atitude suspeita. Avistaram o acusado Gabriel. Na cintura dele, encontraram 70 gramas de entorpecente. O acusado disse que residia na mesma rua e que havia drogas no local. O réu autorizou a entrada dos policiais. Nada foi encontrado. O réu estava 'de "saidinha"'. O acusado falou que, na residência da genitora, havia entorpecentes. Foram até o local, onde a genitora autorizou a entrada. No quarto da irmã do réu, acharam uma mochila com 05 quilogramas de maconha. Conduziram o réu até a delegacia. Estavam em patrulhamento pelo bairro, quando populares avistaram o réu sentado, defronte à residência e fizeram a 'denúncia'. Lograram êxito em abordar o réu. O patrulhamento foi iniciado no começo do período vespertino. A genitora do réu chorou e disse que 'educou o acusado' e não acreditava no que estava acontecendo. A genitora disse que o réu frequentava sua residência, mas não era morador. Não conhecia o réu do meio policial. O réu autorizou a entrada e assinou o documento. Não fez o vídeo antes de ingressar na residência. Quando o canil chegou, já estavam na residência. A mochila estava no quarto da irmã do réu, ao solo.

Aqui, uma ressalva.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE

DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

A testemunha de defesa Nayara de Oliveira Cesario, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) disse que é esposa do réu. Disse que o réu estava de "saidinha". Sua genitora chegou na residência. O réu estava na sala. Policiais entraram no imóvel e disseram que havia autuado uma pessoa e estavam procurando o citado indivíduo. Permaneceram no fundo da residência. Policiais fizeram buscas na residência e, após, citaram que encontraram 60 gramas de drogas com o réu. Os policiais acionaram o canil. Não encontraram mais nada. Na delegacia, apareceram cerca de quatro quilogramas de drogas, cuja origem desconhece. Relaciona-se com o réu desde 2016. Tem dois filhos. O réu está preso desde 2019. A genitora de Gabriel o visitou, por duas vezes, na unidade prisional. Sua sogra chama-se Liene. Sua sogra contou que,

quando chegou do serviço, policiais já estavam na residência. Sua cunhada é Rafaela. O réu estava no interior da residência, quando foi abordado por milicianos. O réu usa drogas. O réu já ficou internado. Sua sogra ficou 'bem indignada' e falou que não tinha ciência dos entorpecentes. As drogas foram encontradas no quarto de sua cunhada.

Sob os preceitos constitucionais, a informante Sra. Liene Cristiana de Oliveira Palma disse, em suma, que chegou do trabalho e tinha uma viatura, com a porta aberta, no local em que reside. Os policiais estavam na escada e na porta do elevador. Na porta, aguardava um policial, que pediu para entrar. Afirmaram que tinha algo em sua casa e, por isso, os deixou entrar, pois tinha a certeza de que não tinha nada. Eles encontraram uma bolsa. Ficou assustada, pois achou que aquilo não estivesse em seu apartamento. A bolsa não pertencia ao Gabriel. Ele não tem acesso ao apartamento, nem sequer as chaves. Nunca viu a mochila apreendida em sua residência. Atualmente, reside com a sua filha e o namorado dela. Na época dos fatos, o namorado de sua filha residia no local. Quando o réu foi preso, o namorado de sua filha "sumiu". Depois, ele retornou, pois sua filha está grávida. Na época dos fatos, o namorado de sua filha não trabalhava. Seu genro chama-se Jonas Rangel. O namorado de sua filha frequentava sua residência antes dos fatos e chegava a pernoitar no local. Atualmente, ela está no sétimo mês de gestação. Sua filha ficou grávida entre dezembro e janeiro. Atualmente, seu genro trabalha como auxiliar de pedreiro. Sua filha trabalhava à época dos fatos no "Chavão". Os policiais disseram: "nós vamos trazer seu filho aqui, pois combinamos com ele". Os policiais pediram-lhe para descer e conversar com seu filho. Quando desceu, havia muitas pessoas que observaram. Os policiais retiraram as algemas de Gabriel. Os policiais falaram que não era necessário que a depoente fosse até a delegacia. A esposa de Gabriel se chama Mayara. O réu e a esposa residem na Rua Pernambuco e possuem dois filhos. A bolsa estava no quarto de sua filha. Os policiais chegaram já acusando o réu. Falou para os policiais que 'aquele cômodo era de sua filha'. Antes da prisão do acusado, os policiais sempre o abordavam. Já fazia três anos que seu filho estava preso. Os fatos ocorreram em dezembro. O réu foi preso por tráfico de drogas. A sua filha chorou muito no dia dos fatos. Soube que seu genro já foi preso, anteriormente, por tráfico de drogas.

O acusado Gabriel Henrique Palma da Silva sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, disse que, no dia 23 de dezembro, estava em gozo de "saidinha". Sua esposa não tinha veículo. Saiu por volta das 08h. Parou no posto e seus familiares não tinham chegado. No local, havia três pessoas que usavam drogas. Comprou entorpecentes deles. 'Depois de um tempo, sua esposa chegou'. 'Foi ao mercado com o dinheiro que sobrou'. No dia 24 de dezembro, ajudou sua sogra a 'fazer a ceia de Natal'. No dia 25 de dezembro, 'fez almoço em sua residência'. Permaneceu na residência nos próximos dias. 'Fumava escondido, pois sua esposa não gostava'. No dia 29 de dezembro, dormia, quando sua sogra chegou. Depois de cinco minutos, os policiais entraram em sua residência, sendo que o sargento estava armado. Os policiais 'queriam arma'. Respondeu que tinha drogas, as quais adquiriu no posto. Os milicianos queriam arma de fogo e disseram que se o interrogando 'não entregasse as armas, apareceriam muitas drogas'. Levou os policiais até o seu quarto e nada foi encontrado. Os policiais acionaram o canil. O canil não achou nada. Os policiais questionaram sobre seus familiares. Os policiais ameaçaram 'pegar seus filhos'. Posteriormente, os policiais saíram do local. Falou que não tinha nada de ilícito. Após uma hora, foi algemado e encaminhado para a delegacia. Os policiais foram até a residência de sua genitora. Os policiais o obrigaram a fazer um vídeo, caso contrário, prenderiam sua genitora. Os policiais lhe retiravam da viatura e 'obrigaram a fazer um vídeo'. Quando saiu da unidade prisional, sua esposa o buscou na rodoviária. Na residência de sua genitora, encontraram maconha. Fazia "bicos" e trabalhava 'numa loja de extintor'. Tem antecedente criminal por tráfico de drogas. É usuário de drogas e já esteve internado. Reside na Rua Pernambuco, desde 2016. Em 2019, quando foi preso, sua genitora só o visitou por duas vezes. Não frequentava a residência de sua genitora. Na residência de sua genitora, residem sua irmã e seu cunhado. Não o conhece. Sua sogra e esposa ficaram no fundo do imóvel com outros policiais. Os policiais afirmaram que "se não entregasse as armas, fariam algo

contra seus familiares”.

Pela prova colhida, de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

De início, nada há nos autos que denote que os policiais 'quisessem prejudicar o acusado'.

O próprio Sargento Abraão citou que não conhecia o acusado dos meios policiais.

Depois, o réu foi abordado em outras ocasiões por policiais (em pelo menos outras três oportunidades), sendo que jamais foi preso.

Na hipótese dos autos, inegável que o réu portava entorpecentes.

Aliás, segundo ele, dias antes do ocorrido, teria adquirido o entorpecente em um posto.

De se citar, ainda, que, após abordarem o réu (posteriormente à “delatio criminis inominada” e ao regular patrulhamento), os policiais encontraram a droga.

Aqui, um corte na ocorrência.

O acusado estava na “primeira saidinha” (fls. 09).

Ainda assim, adquiriu drogas e as portava.

Depois, mencionou que “foi obrigado a fazer um vídeo pois, caso contrário, os policiais prenderiam a mãe”.

Ora, a genitora, informante, afirmou que desconhecia os motivos pelos quais a bolsa estava em seu apartamento.

Ademais, não se podem concluir que o delito foi cometido pelo então namorado da irmã.

Contudo, não é razoável que nem sequer a irmã tenha sido arrolada como informar apta a elucidar a “dúvida” que tentaram lançar, mas sem sucesso.

De outro lado, como dito, as diligências foram realizadas em dois imóveis.

Por isso, a comunicação foi posteriormente realizada (fls. 27/29).

Mesmo assim, foi lavrado o BO/PM (fls. 199/207), há o horário de início (aproximado) e do fim das diligências, com as autorizações e assinaturas de Gabriel e de sua mãe, autorizando as buscas nas residências.

Além disso, o monitoramento do policial Sgto Abraão, efetivamente, demonstra que ele estava na Rua Uruguai (fls. 208/224).

Tais circunstâncias denotam, ao menos pelo que se amealhou aos autos até o presente momento, que ele não cometeu o delito descrito no art. 342, §1º do Código Penal.

Em outras palavras, o depoimento é coerente e não caracteriza “falso testemunho”, até porque em consonância com o arcabouço probatório colhido.

Nesse sentido:

Ementa: Apelação. Tráfico de drogas e receptação. Recurso defensivo. 1. Condenação adequada. Materialidade comprovada pela apreensão das drogas e pelo exame químico-toxicológico. Prova do crime antecedente representada pelas declarações da vítima em fase preliminar. Autoria certa. Depoimentos firmes dos policiais militares confirmando as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado. Versão inconsistente fornecida pelo acusado e pela informante. Destinação comercial demonstrada. 2. Pleito objetivando a absolvição pelo crime de receptação por ausência de dolo ou, alternativamente, a desclassificação para receptação culposa. Impossibilidade. Dolo caracterizado. Existência de elementos a indicar que o réu tinha ciência quanto à ilicitude do bem por ele adquirido. 3. Dosimetria. Pena-base fixada no limite mínimo. Menoridade relativa reconhecida com aplicação da Súmula 231/STJ. Tráfico privilegiado aplicado em sentença com redução no patamar máximo. 4. Regime aberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. Recurso improvido.

(TJSP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1501298-69.2020.8.26.0545, relator Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, julgado em 03/08/2022)

Portanto, nos termos do art. 40 do CPP, a contrario sensu, não restou caracterizado crime de falso testemunho, restando sem lastro a versão defensiva:

Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juizes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.

Tampouco é possível a desclassificação para o delito de consumo, nos moldes do art. 28, §2º da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, o acusado possui condenação anterior pela mesma prática delituosa.

Em acréscimo, a quantidade de droga apreendida (cerca de 5 Kg) denota que era destinada ao comércio espúrio.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Sob outro aspecto, deve o acusado Gabriel permanecer custodiado.

O réu possui dois feitos (o primeiro por roubo majorado e o segundo por tráfico de drogas e receptação), com condenações transitadas em julgado, caracterizando reincidências (fls. 50/53, 0030863-66.2013 e 1500365-80.2019).

Por isso, a manutenção da custódia serve para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nessa senda:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACAUTELADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PROPORCIONALIDADE CONSTATADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento este chancelado por esta Corte, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício, o que não se coaduna à hipótese dos autos.

2. Constrangimento ilegal não configurado, pois, conforme exegese teleológica do art. 282, caput, incisos I e II, c.c. as cautelares pessoais não prisionais estatuídas no art. 319, ambos do Código de Processo Penal, contornados pela sistemática estatuída na Lei n. 12.403/11 e sob a égide da proporcionalidade (formal e material), afigura-se suficiente e adequada, conforme as peculiaridades do caso concreto, a imposição ao acautelado da proibição de ingestão de bebidas alcoólicas e uso de estupefacientes quando este confessa, no bojo da persecução criminal, ser usuário (dependente químico) e ter praticado o delito sob os efeitos de tais substâncias, as quais potencializam - caso não evitadas - o risco no cometimento de novas infrações.

3. Na hipótese, a necessidade e adequação das medidas não prisionais em testilha foram justificadas pelas instâncias ordinárias com base nas circunstâncias do fato e nas condições pessoais do agente, permeadas pela confissão da prática delitiva de suposto furto "motivada pela fissura da droga" e, conforme evidenciado na audiência de custódia, consulta ao SISP revela que este teve outras duas ocorrências policiais anteriores pela prática da mesma espécie de crime, malgrado ser tecnicamente primário.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC 395336 / SC, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 24/04/2018)

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

A culpabilidade é acentuada, tendo em vista que o acusado cometeu o crime enquanto estava em saída temporária (a primeira).

As circunstâncias e consequências não transbordam as barreiras do tipo.

Depois, a quantidade de droga (quase cinco quilos de maconha) também serve para exasperar a reprimenda inicial.

Isto por que, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que a natureza, bem como a quantidade de drogas, são circunstâncias preponderantes.

Tal conclusão é amparada pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. DESPROVIDO.

I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

III - No presente caso, afastou-se o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 348 (trezentos e quarenta e oito) pedras de crack, 2 (dois) cigarros de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, além da apreensão de 1 (uma) arma de fogo, calibre 380 e 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre. Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e justifica o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

IV - "[...] A questão discutida neste recurso especial não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, tal como ocorre, por exemplo, com a valoração das circunstâncias judiciais (uma a uma). O caso, diversamente, demanda apenas o reexame da aplicação da pena, providência admitida em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou de equívoco evidente de fundamentação das circunstâncias judiciais (como no caso) ou, ainda, de erro de técnica no critério trifásico de aplicação da pena" (AgRg no REsp n. 1.475.447/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015). Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1753254 / MG, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Assim, a pena é exasperada em 1/3, perfazendo 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, o réu, como dito, possui duas reincidências em seu desfavor.

Assim, a pena é agravada em mais 1/5, atingindo 8 (oito) anos e reclusão e 799 (setecentas e noventa e nove) diárias.

Ainda na fase intermediária, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Não reconhecimento da participação de menor importância – Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor – Concessão de regime inicial aberto – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, o acusado é multireincidente, um dos feitos, específico.

Nem se fale que haveria bis in idem na utilização da reincidência na segunda fase e na derradeira, porque o instituto é utilizado de maneira diversa.

Na intermediária, a reincidência é fator para agravar a pena, já que sempre deve agravar a reprimenda, nos estritos termos do art. 61 "caput" do Código Penal, e,

ressalvadas as hipóteses legais.

Já na última fase é pressuposto para negar o redutor previsto no art. 33, §4º da lei 11343/06, salientando-se que os requisitos lá plasmados são cumulativos.

A variação da diminuição na minorante é cotejada com fatores diversos, tais como quantidade e natureza da droga (quando não utilizados na primeira fase), as circunstâncias da ocorrência, a personalidade do acusado, ou seja, de modo geral, o próprio art. 42 da lei 11343/06.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte estadual, na terceira fase da dosimetria, sopesou não apenas a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito para concluir que os acusados se dedicariam a atividades delituosas, especialmente ao narcotráfico, motivo pelo qual não há falar em bis in idem.

2. A simples reincidência dos réus já é elemento suficiente para, por si só, impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse benefício aos acusados reincidentes.

3. Se ainda não houver decorrido o prazo de 5 anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior é geradora de reincidência, independentemente de ela ser ou não pela prática do mesmo delito.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1382648 / SP, por unanimidade, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 18/06/2019)

Por isso, a pena atingida na segunda fase é a definitiva.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos acusados.

Fixo o regime inicial fechado.

O réu Gabriel é multireincidente.

Além disso, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 (nos termos do art. 33, §3º do Código Penal) não foi considerado inteiramente favorável.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.

3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

4. Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, a sua aplicação

demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas ou integrar organização criminosa. No caso dos autos, o paciente é reincidente, não fazendo jus a aplicação da redutora.

5. Quanto ao regime, tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o paciente é reincidente, o regime inicial fechado é mais adequado ao caso, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

6. Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o quantum da pena supera o limite previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 695249 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/10/2021)

Não se pode olvidar, ainda, que cometeu o crime em plena "saída temporária", o que denota que o regime mais gravoso é o único apto a reprimir, e também, ressocializar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL, e, deste modo, CONDENO o acusado Gabriel Henrique Palma da Silva, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Nego ao acusado Gabriel o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados.

Quanto aos entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os acusados a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA